

刑法
No274

H22-3

(配点：2)

月 日

月 日

窃盗罪の実行の着手に関する次の1から5までの各記述における甲の行為を判例の立場に従って検討し、誤っているものを2個選びなさい。

1. 甲は、乙がズボンのポケットに財布を入れるのを見て、同財布をすり取ろうとして同ポケットに手を差し伸べ、ポケットの外側に触れた。この場合、財布に触っていないので、窃盗罪の実行の着手は認められない。
2. 甲は、電柱に架設されている電話線を盗もうと考え、電柱に登って切断用具を電話線に当て、その切断を始めたが、警察官に発見されたため、電話線の被膜を傷付けただけにとどまった。この場合、電話線を切断していなくても、窃盗罪の実行の着手が認められる。
3. 甲は、乙所有の自動車を運転して盗み出すため、不正に入手した同自動車のスペアキーを使い、駐車場に駐車してある同自動車の運転席のドアを開けた。この場合、運転席に乗り込む前でも、窃盗罪の実行の着手が認められる。
4. 甲は、金品を盗もうと考え、深夜、無人の店舗内において、懐中電灯で真暗な店内を照らしたところ、食品類が積んであることが分かったが、なるべく現金を盗みたいと思い、現金がある精算レジに近づいた。この場合、未だレジ内を物色していないので、窃盗罪の実行の着手は認められない。
5. 甲は、不正に取得した乙名義のキャッシュカードを使用して同人の預金口座から現金を引き出そうと考え、同カードを銀行の現金自動預払機に挿入し、暗証番号を入力した。甲は、同カードの正しい暗証番号を知っていたが、その入力を誤ったため払戻しを受けることができなかった場合でも、窃盗罪の実行の着手が認められる。

No274

H22-3

窃盗罪の実行行為

正解

1、4（順不同）

正答率

95%

窃盗罪の未遂は罰せられるが（243条）、予備は罰せられないから、特に実行の着手時期が問題となる。この点、判例は、他人の財物に対する事実上の支配を侵すにつき密接な行為をした時に窃取行為の開始があったとしている（大判大6.10.11）。この内容について、学説は、実質上結果発生の実際の危険が発生した時点をもって実行の着手とするものと解している。そして、窃盗罪については、財物の性質、形状及び行為の態様、犯行の日時・場所を考慮して、特別の障害がない限り、他人の財物を自己の占有に移すことが経験則上一般に可能となる時点とすべきであるとされている。

1 誤っている

本記述では、甲が財布の存在を知りつつ、財布をすり取ろうとして手を差し伸べ、ズボンのポケットの外側に触れた場合に、財布に触れていなくても、窃盗罪の実行の着手が認められるかが問題となる。この点、被害者が金品を所持していることを知りつつ、窃取しようとして手を伸ばし、ズボンのポケットの外側に触れた事案において、判例は、実行の着手が認められるとしている（最決昭29.5.6）。本記述においても、特別の障害がない限り、そのままズボンのポケットに手を入れ財布を甲の占有下に移すことが可能と考えられるから、甲の行為によって、結果発生の実際の危険が生じているといえる。よって、財布に触れていなくても、窃盗罪の実行の着手が認められる。なお、ポケットに財物があるかどうかを確かめるいわゆるアタリ行為は、未だ窃盗の準備・予備段階であり、窃取行為とは別個の行為であるとして、実行の着手は認められないことがある。もっとも、本件甲は、乙がズボンのポケットに財布を入れるのを見ており、財物があるかどうかを確かめるものではないから、甲の行為は、アタリ行為には当たらない。

2 正しい

本記述では、甲が電話線を盗むため、電柱に登り、切断用具で電話線の切断を始め、電話線の被膜を傷付けた場合に、電話線を切断していなくても、窃盗罪の実行の着手が認められるかが問題となる。この点、切断用具で電話線を切断しようとしたが、巡査に逮捕されて電話線窃取の目的を遂げなかった事案において、判例は、実行の着手が認められるとしている（最決昭31.10.2）。本記述においても、特別の障害がない限り、そのまま切断が完了し電話線を甲の占有下に移すことが可能と考えられるから、甲の行為によって、結果発生の実際の危険が生じているといえる。よって、電話線を切断していなくても、窃盗罪の実行の着手が認められる。

3 正しい

本記述では、甲が不正に入手した乙所有の自動車のスペアキーを使って、同車のドアを開けた場合、運転席に乗り込む前でも、窃盗罪の実行の着手が認められるかが問題となる。この点、財物たる自動車の性質上、スペアキーで運転席のドアを開ければ、自動車の中に入り、スペアキーでエンジンをかけ、容易に走り去ることができる。そのため、スペアキーで自動車のドアを開けた時点で、特別の障害がない限り、自動車を自己の占有下に移すことが可能と考えられる。そうすると、甲の行為によって、結果発生の実際の危険が生じているといえる。よって、運転席に乗り込む前でも、窃盗罪の実行の着手が認められる。なお、裁判例は、車上狙いの犯人が、自動車の鍵穴にドライバーを差し込み、こじ開けた事案において、窃盗罪の実行の着手が認められるとしている（東京地判平2.11.15）。

4 誤っている

本記述では、甲が、深夜、無人の店舗内において、懐中電灯で真暗な店内を照らし、なるべく現金を盗みたいと思い、現金がある精算レジに近づいた場合、レジ内を物色していなくても、窃盗罪の実行の着手が認められるかが問題となる。この点、犯人が深夜に店に侵入し、なるべく現金を盗りたいと考え、現金のありそうな煙草売場に近づこうとした事案において、判例は、実行の着手が認められるとしている（最決昭40.3.9）。本記述においても、特別の障害がない限り、そのままレジから現金を甲の占有下に移すことが可能と考えられるから、甲の行為によって、結果発生の現実的危険が生じているといえる。よって、未だレジ内を物色していなくても、窃盗罪の実行の着手が認められる。

5 正しい

本記述では、甲が乙名義のキャッシュカードを使用して同人の預金口座から現金を引き出そうと考え、同カードを現金自動預払機に挿入した場合、払戻しを受けることができなくても、窃盗罪の実行の着手が認められるかが問題となる。この点、現金自動預払機においては、キャッシュカードを現金自動預払機に挿入し、暗証番号を入力すれば、現金の払戻しを受けることができる。そのため、キャッシュカードの正しい暗証番号を知っていた場合、キャッシュカードを現金自動預払機に挿入した時点で、特別の障害がない限り、現金を自己の占有下に移すことが可能と考えられる。そうすると、甲の行為によって、結果発生の現実的危険が生じているといえる。よって、払戻しを受けることができなくても、窃盗罪の実行の着手が認められる。なお、裁判例は、窃取したキャッシュカードを使用して、現金を引き出すための前提として残高照会をした事案において、窃盗罪の実行の着手を認めている（京都地判平18.5.12）。